

多边贸易、市场规则与技术标准定价*

马 一 德

摘 要：技术交互利用催生技术标准，技术标准许可贸易是全球多边贸易的重要内容。单边技术标准定价规则引发大量诉讼，使得以技术为生的市场主体疲于应对，无暇升级自身经济结构。技术标准的推行需要公平、合理、无歧视的多边贸易体制。作为技术标准的法律形态，标准必要专利许可费定价规则是多边技术贸易规则体系的核心内容。现有标准必要专利许可费定价规则表明，不同国家基于各自利益，在贸易体制外主动或被动制定单边规则，致使技术标准定价规则碎片化。以市场因素整合技术定价规则，重塑多边贸易体制的职能，实现多边贸易规则体系的现代化，增强多边贸易体制对全球价值链的适应性，是解决技术标准定价规则冲突的可行方案。倡导建立以市场为标准必要专利定价规则，使不同层级发展水平的国家能够在多边贸易体制下共享技术革命成果，以此推动全球均衡、包容、普惠发展，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和方案。

关键词：多边贸易 知识产权 技术标准 标准必要专利 市场定价

作者马一德，中南财经政法大学文澜特聘教授（武汉 430073）。

知识产权基于市场交易而生，没有市场就没有知识产权，知识产权是贸易全球化的重要内容。专利的生命在于许可使用，通过技术市场交易获得价值。通过设定技术标准进行技术许可使用，是技术贸易发展的必然形式。技术标准是经标准化组织批准的、非强制执行、可重复使用的通用技术方案规则和指南，其实质是对技术设立的必须符合要求的条件以及能达到此标准的实施技术。技术标准使不同生产者的产品能可靠地以不可见的方式交互兼容，各种技术设施通过技术标准实现移动连接，形成了物质世界的网络效应，^① 使得与互联网并行的物联网^②得以建立。在贸

* 本文为中央马克思主义理论研究和建设工程重大项目兼国家社会科学基金重大项目“知识产权保护与创新研究”（2016MZD022）阶段性成果。

① Carl Shapiro and Hal R. Varian, *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*, Boston: Harvard Business School Press, 1998, pp. 45-46.

② Pelle Högnelid and Thomas Kalling, “Internet of Things and Business Models: Empirical

易全球化过程中，技术标准正成为产业竞争的制高点、创新成果产业化的关键环节、高新技术尤其是信息技术发展的前导规制，技术标准关系到对未来产品、未来市场和
国家经济利益的竞争。在技术标准普遍专利化的背景下，技术标准与专利技术密不可分，技术标准是专利技术追求的最高形态，标准必要专利的许可贸易在多边技术贸易
中占据绝对比重。标准必要专利许可费是影响技术标准市场价值的决定性因素，为预防标准必要专利权利人以许可费为手段进行专利劫持，标准化组织要求技术标准参与者承诺以“公平、合理和非歧视性”（FRAND 原则）的许可费授权第三方使用。

随着各国经济相互交织、相互影响、相互融合成统一的整体，发达国家以技术标准为核心打造新的全球研发和生产网络，整合全球创新资源推进创新研发，利用
知识产权占据全球生产价值链上游的高附加值环节。在 FRAND 原则内涵模糊且无强制约束力的情形下，发达国家通过双边、多边贸易协定的形式打造新一轮全球技术
标准定价规则，以巩固传统的价值链利益分配格局，形成了与多边贸易体制背道而驰的单边主义准则，标准必要专利许可费的司法定价规则即为其典型。发达国家
法院通过对定价规则的操控而裁决确定标准必要专利许可费（见表 1），^① 实现保护各国优势产业的目的，维持其在全球范围内的价值链优势。标准必要专利许可费司
法定价规则不同，标准必要专利实施者难以同权利人（尤其是发达国家签订贸易协定的发展中国家的技术标准实施者）就裁决结果达成共识，这促使发展中国家法院
不得不采用基于本国利益的定价规则，以换取标准必要技术的使用，形成被动的防御态势。在贸易全球化趋势下，单边制定技术标准定价规则引发了大量诉讼，^② 迫使以技术为生的市场主体疲于应诉（见下页表 2），且直接影响了标准必要专利的产
量。^③ 技术标准定价规则的单边化所引发的危机是可预见的高概率事件，已然成了危及多边贸易体制的“灰犀牛”事件。

表 1 全球主要的标准必要专利许可费裁决

序号	案件	计算方法	裁判法院
1	Microsoft v. Motorola ④	假设性协商法	华盛顿西区联邦地区法院（美国，2013）

Illustrations of How the Business Model Concept Helps Us to Understand Strategic Implications of Internet of Things Investments,” IEEE 9th International Conference on
Standardization and Innovation in Information Technology, 2015, p.13.

① 例如，针对标准必要专利许可费的确定，欧美司法机关目前存在不同的路径选择，欧洲倾向于通过对谈判行为的约束，推动双方达成许可协议，不倾向于通过司法裁决标准必要专利的单费率，而美国却倾向于通过司法确定费率。

② 在有关标准必要专利的诉讼中，主要以许可费纠纷和禁令诉讼为主，而标准必要专利的禁令诉讼往往是由专利权人和实施者难以就使用许可费达成共识所引起的。

③ IPlytics EU Report on Landscaping SEPs 2016, p. 24.

④ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176 (W.D. Wash. 2013).

续表 1

序号	案件	计算方法	裁判法院
2	In re Innovatio IP Ventures ^①	专利价值分摊	伊利诺伊州北区联邦地区法院（美国，2013）
3	Apple Japan v. Samsung ^②	峰值法	知识产权高等裁判所（日本，2014）
4	Unwired Planet v. Huawei ^③	可比许可协议法	高等法院专利法庭（英国，2017）
5	Ericsson v. TCL ^④	Top-Down 法； 可比许可协议法	加利福尼亚州中部地区法院（美国，2017）

表 2 全球 SEP 主要权利人及市场占有率和诉讼情况^⑤

公司	已公布标准 必要专利	市场覆盖指数	技术相关性 指数	专利族	引证 SEP 份额（%）	其他 SEP 的 引证份额（%）	遭诉讼的 专利
高通	20678	1.72	1.13	1314	27.40	6.02	888
诺基亚	13393	1.66	0.88	1899	36.42	5.31	557
IDC	12522	1.68	0.77	1081	29.56	4.72	978
LG 电子	10772	1.76	1.73	1114	43.99	3.51	173
三星电子	10618	1.54	1.73	1596	32.44	3.57	502
爱立信	9396	1.62	1.09	1468	34.68	3.12	467
华为	6500	1.76	1.28	1926	48.51	2.85	29
松下	6326	1.77	1.10	1486	52.56	1.74	572
谷歌	4576	1.40	1.26	1504	56.13	1.65	67
黑莓	2319	1.29	1.28	325	43.08	0.61	5
索尼	2289	1.39	1.16	542	26.12	0.16	171
西门子	2209	1.03	0.71	356	43.82	0.75	49
夏普	2170	1.85	1.52	564	54.82	0.40	45
诺基亚西门子 通信公司	2073	1.65	1.13	591	43.22	1.34	52
飞利浦电子	1704	1.44	0.50	298	18.26	0.45	300
中兴	1640	1.63	1.95	560	41.71	0.86	0
三菱电机	1387	1.26	0.63	239	47.55	0.59	134
Rockstar	1174	1.29	2.08	198	47.53	0.36	12
阿尔卡特	1105	1.30	0.98	415	45.63	0.48	22

① In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

② 参见日本知財高判平成 26.5.16 平成 25（ネ）10043。

③ Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd., [2017] EWHC 2988 (Pat).

④ TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

⑤ IPlytics EU Report on Landscaping SEPs 2016, pp. 27-29.

续表 2

公司	已公布标准必要专利	市场覆盖指数	技术相关性指数	专利族	引证 SEP 份额 (%)	其他 SEP 的引证份额 (%)	遭诉讼的专利
东芝	953	1.07	0.75	301	24.66	0.03	41
Innovative	796	0.63	1.38	91	61.31	0.50	8
日立	549	0.81	0.77	220	40.07	0.36	16
英特尔	479	1.34	0.94	66	43.63	0.16	60
三洋电气	465	2.05	1.45	64	26.45	0.24	56

当前，“全球产业布局在不断调整，新的产业链、价值链、供应链日益形成，而贸易和投资规则未能跟上新形势，机制封闭化、规则碎片化十分突出。”^① 为推动构建公平、合理、无歧视的多边贸易规则体系，促进技术要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，必须整合全球的技术标准定价规则，建构科学的多边技术贸易争端解决机制，维护多边贸易体制的稳定。国内外学者在确定科学的定价规则过程中作出了有益探索，^② 但皆因其未能厘清现有司法定价规则的规律而陷入困境，难以提出具有可操作性的合理方案。为弥合分歧，凝聚共识，本文找出了标准必要专利许可费定价规则碎片化的成因，进而提出建立最大限度缩小法官自由裁量空间之规则，形成以市场主导而非以司法为主导的技术定价规则，以此消除各国因标准必要专利定价规则之分歧而形成的贸易壁垒，促使各方维护多边贸易规则的权威性和

① 习近平：《共担时代责任，共促全球发展》，《习近平谈治国理政》第 2 卷，北京：外文出版社，2017 年，第 479 页。

② 我国学者对该问题提出了具体解决方案，参见马海生：《标准必要专利许可费司法定价之惑》，《知识产权》2016 年第 12 期；李剑：《标准必要专利许可费确认与事后之明偏见——反思华为诉 IDC 案》，《中外法学》2017 年第 1 期；赵启杉：《标准必要专利合理许可费的司法确定问题研究》，《知识产权》2017 年第 7 期。国外研究主要分三个方向进行：一是对司法裁决使用方法的修正；二是提出辅之以市场解决方案，增加市场定价的影响因子；三是根植于合作博弈理论，提出标准必要专利许可费的棒球式仲裁解决模式。参见 Rebecca Haw Allensworth, “Casting a FRAND Shadow: The Importance of Legally Defining ‘Fair and Reasonable’ and How ‘Microsoft v. Motorola’ Missed the Mark,” *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol.22, no, 1, 2004, pp. 235, 250-251; Jay Pil Choi, “FRAND Royalties and Injunctions for Standard Essential Patents,” *Global Economic Review*, vol. 45, no. 3, 2016, pp. 233, 248; Marc Rysman and Tim Simcoe, “A NAASTy Alternative to RAND Pricing Commitments,” *Telecommunications Policy*, vol. 35, no. 11, 2011, pp.1010,1014-1016; Jorge L. Contreras, “Fixing Frand: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing,” *Antitrust Law Journal*, vol.79, no.1, 2013, pp. 47,54; J. Gregory Sidak, “Mandating Final-Offer Arbitration of FRAND Royalties for Standard-Essential Patents,” *Stanford Technology Law Review*, vol,18, no.1, 2014, pp.37-38.

有效性,为全球知识产权治理提供有益探索,为多边贸易体制的稳定、全球贸易的健康发展和构建人类命运共同体贡献中国智慧和方案。

一、多边贸易中技术标准定价规则的碎片化

在多边贸易体制中,各国力求将自身利益诉求植入国际贸易秩序中,多重博弈已成为一种常态。^①在技术标准许可贸易争端中,此种博弈的结果突出表现为标准必要专利许可费司法定价规则的碎片化。鉴于多边贸易体制规则的完整性,定价规则碎片化会对其有效性和权威性构成潜在威胁,为防止这种威胁转化为实际危险,须对定价规则碎片化的成因进行明晰,方可提出解决之道。

(一) 技术标准定价规则碎片化的成因

当前标准必要专利许可费纠纷的司法定价规则集中于专利价值分摊法。专利价值分摊法的基础在于技术分摊,着眼于探求涉案专利自身的技术价值。^②自下而上的分摊方式,是对个体专利的增量值进行评估,即确定涉案专利技术对整体产品价值的贡献增量,涉及确定涉案专利对标准的重要性及标准对产品的重要性。^③对涉案专利进行自下而上的价值评估,有可能导致专利费堆叠,而且这种可能性的发生概率较高。^④这根源于许可费计算连续自下而上的性质。另外,多数产品的技术方案除了标准必要专利之外,还包括大量非标准必要专利和非专利技术,将涉案专利从如此复杂的技术组合中剥离出来并评估其价值并非易事。^⑤此外,自下而上的分摊方式还将导致标准必要专利权利人过度主张其一些标准“非必要”专利具有“必要”性。^⑥专利权人的过度宣称行为会歪曲特定标准包含的专利总体范围,夸大其实际技术价值贡献,

① 参见张亚斌、范子杰:《国际贸易格局分化与国际贸易秩序演变》,《世界经济与政治》2015年第3期。

② 参见赵启杉:《标准必要专利合理许可费的司法确定问题研究》,《知识产权》2017年第7期。

③ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176 (W.D. Wash. 2013).

④ “当技术标准涉及数百个、甚至数千个专利时,可能会产生许可费堆叠,如果专利实施者被迫向所有专利权人支付许可费,许可费将相互堆叠,并可能在总量上过高。”Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

⑤ 尤其在侵权诉讼中,与涉案专利相关的其他非专利技术的权利人往往无处可查,如此,便需让被控侵权人承担证明其他非专利技术的贡献率的责任,以表明涉案标准必要专利的相对价值,这需要专业的知识,而在多数情况下被控侵权人并不具备这些知识。

⑥ 标准制定组织会在推行标准时公开“必要”专利,但该组织本身往往不会验证所公开专利的必要性,是否将专利指定为标准必要专利,完全由专利权人自行决定,仅在发生诉讼时该专利才会经受必要性的审查,这种“激励机制”,也会导致标准制定组织的参与者过度宣称其非必要专利为必要专利。

如果能够更为仔细地评判相关专利的必要性，则可能得出与专利权人声明相反的结论。

鉴于自下而上分摊法的固有缺陷，法院采用了自上而下的替代方案。自上而下分摊法的适用分为确定技术标准许可费总额和计算具体专利的技术价值量两个步骤。许可费总额的提前设置，使参与标准的专利权人对其投资回报有所预期，鼓励其积极参与技术标准的制定；排除了因标准使许可费增加的可能性，消除了因专利挟持致许可费增加的猜疑；^① 也有效规避了许可费堆叠的风险。^② 但对总的许可费值的确定，即使多是一个区间值，现有司法判例皆未提供可信赖的数据来源。此外，确定许可费总额的方法多以静态视角看待现有技术标准，未预期到标准的后续新版本。而改进之后的标准总是会吸纳一些有价值的功能，^③ 专利权人若能提供证据以证明后续标准增加之价值，则会考虑采用比最初更高的许可费总额，从而否定最初宣布的许可费总额。这些情形使得任一种最初确定许可费总额的方法处于存疑的状态。

依据标准必要专利的技术贡献度，将总的许可费分摊至标准中的每项必要专利，是自上而下分摊法的关键步骤。但提出证明涉案专利贡献度的有力证据往往并非易事，^④ 证明过程往往耗费较多时间、经济成本。易于判断者，乃是产品购买力由涉案专利所驱动时，^⑤ 可判定涉案专利对标准和产品的贡献度达到了峰值；但随着技

① TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

② 许可费堆叠是由多个专利权人行为所造成的客观结果，在跨领域技术快速融合、标准必要专利所有权归属日益分散化的必然趋势下，此种风险并非仅停留在猜想阶段，而是一种客观存在的风险，只不过当下难以通过精确的数据予以计量，而较为经济的做法，是在许可使用费率计算阶段就规避这种风险。

③ 这些新加入的功能可区分为两种类型：一是对现有标准技术功能的简单扩展或者是一些常识性技术的增加，这类技术的增加可被标准必要专利权人所预料，故该情形会使实施者相信涉案专利权人依然会促使市场以现有标准为首选；二是后续版本的标准在现有标准基础上增加了无法被预见的功能，全新的标准是在原有的标准基础上发展而来的，涉案专利仍在发挥其必要性的作用。

④ 例如，在 TCL 诉爱立信案中，当专利价值分摊法无法区分专利在标准中的贡献率和专利本身的技术价值，爱立信一方主张应该考虑其专利在纳入标准前的技术价值，提出的根据是专利在标准中的重要性和贡献率，均未被法院采纳。TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017)。

⑤ 在华为诉三星案中，法院认为，关于涉案专利的贡献度问题，基于操作简便、交互方式友好的图形操作界面在增强用户粘性、提升品牌认可度、增加产品销售额等方面的作用，可以认定图形操作界面对于智能移动终端产品的利润具有实质性贡献。在智能手机尚未普遍推广，用户还不熟悉多屏桌面的情况下，涉案专利创造性地提出了长按钮组件缩小页面的方案，启发性地引导消费者熟悉并充分使用多屏桌面，且该操作简便，原审认定涉案专利具有较高创造力、对移动终端智能化具有巨大推动力，并无不当。参见福建省高级人民法院（2017）闽民终字第 501 号民事判决书。

术成熟度越来越高,该情形发生的概率较小,普遍情形是多项技术共同形成产品购买力,分摊了产品的技术贡献度。为降低专利贡献度的举证难度,各国法院设计了不同的替代方案。

一是提案贡献法。以涉案专利在技术标准制定过程中被作为提案的次数为依据,计算其对最终技术标准的贡献度。作为分析各方在许可谈判时可用的专利贡献度指标,被提案的次数是一种客观存在的证据,不依赖对贡献度的猜想。但此种方案的缺陷也常被诟病,即无法计算在制定标准后取得的专利贡献度,仅适用于参与标准制定的专利,致使该方案难有普遍适用性。

二是引用贡献法。与提案贡献法相对应,引用贡献法根据涉案专利在后续专利申请文件中被引用的次数来证明其贡献度。但使用前瞻性引用分析证明专利贡献度的难度较大,无法判定当事人是否具有相同的激励引用潜在的现有技术,尤其在存有多个技术标准的情形中。^①

三是专利计数法。该方法是以均等分配技术价值来简化价值分摊,除有直接证据可证明不同技术具有不同贡献度。当无法以不同的专利贡献度分摊价值量,只能按照专利的数量均等分摊。当涉案专利数目达到一定规模时,专利计数法的可操作性使其具有普遍适用性,且使得各种尝试探求每项专利的价值的做法变得不再那么合理。但当涉及一项奠定标准技术方案基础的专利时,专利计数法的缺陷就会被放大。此简化方法还会诱导标准必要专利权利人扩大生产其所拥有专利的数量,把具有单一性的技术方案拆分为多份申请。

四是替代技术法。以替代技术衡量涉案专利的贡献度,根据在采用该专利时其他可用选项的多少,以及相对于其他选项的贡献值增量认定其贡献,并对涉案专利进行了贡献等级的排列。^② 但该方法仅关注涉案专利,并未将该分析方法应用于标准中其他专利,所得出的价值份额是单位不一致的比率。^③ 该方法也忽略了决定标

① TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

② TCL对爱立信的专利进行了贡献等级的排列,贡献等级1意味着没有确定的可行替代专利,等级2代表该专利相对于替代专利而言作出了适度的改进,等级3代表该专利相对于替代专利而言具有边际改进的特征,等级4代表该专利相对替代专利而言没有提供对标准的改进。TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

③ 在TCL诉爱立信案中,法院认为,该方法只分析了涉案标准必要专利的贡献,将其与其他标准必要专利进行分割处理,所得的贡献分数也仅是就涉案标准必要专利自身而言,但其价值分摊是与其他标准必要专利共同进行的,所以无法比较其等级序列,以确定专利的贡献度。法院最后未采纳此种方法。TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

准必要专利贡献的替代技术是如何影响其价值的事实问题和法律问题。^①

(二) 技术标准定价规则碎片化的形成

专利价值分摊法聚焦于涉案专利的技术价值，为标准必要专利许可使用费的确 定提供了具有一定严谨性的方案，使法院能根据客观考虑和正确假设予以确定。但 此种“专利—专利”模式使法院在确认涉案专利的价值时，因缺乏相应的技术信息 和经济信息，无法准确认定涉案专利的价值，所采取的替代方案反而使问题变得更 为复杂。对探求专利价值目标的执着，为各国法院能根据自身利益而选择不同定价 规则提供了空间。围绕产业保护等自身利益，法院在适用专利价值分摊法时，对于 涉案专利的技术价值的确定，可通过分配当事人的举证责任和设定证据标准具有可 自由操作的诉讼程序，亦可通过对举证难度较大环节的替代方案的不同选择，将其 目的内化于规则的选择之中，即使当事人意识到法院所采用的方案具有缺陷，但终 因无法提出更为完善的解决方式而被迫接受。各国的利益诉求往往不同，无法在涉 案专利的价值认定上达成共识，众多个案的法律裁决与复杂的经贸博弈纠缠在一起， 使得多边贸易规则日趋碎片化。^②

在 多 边 贸 易 体 制 中 ， 技 术 标 准 定 价 规 则 的 碎 片 化 ， 源 于 标 准 制 定 组 织 的 定 价 规 则 难 以 回 应 当 下 价 值 链 贸 易 模 式 ， 无 法 实 现 成 员 特 别 是 关 键 成 员 的 共 赢 诉 求 。 根 据 价 值 链 理 念 ， 跨 国 公 司 综 合 分 析 全 球 的 成 本 状 态 ， 开 创 生 产 地 转 移 和 离 岸 生 产 等 新 型 生 产 模 式 ， 这 些 变 化 了 的 贸 易 方 式 对 贸 易 规 则 有 了 新 需 求 ， 其 更 关 注 的 不 再 是 传 统 意 义 的 贸 易 自 由 化 ， 而 是 如 何 降 低 在 全 球 市 场 运 营 的 综 合 成 本 ， 降 低 货 物 和 服 务 传 输 的 不 确 定 性 ， 扩 大 其 世 界 范 围 内 的 合 作 能 力 ， 等 等 。^③ 在 多 边 贸 易 规 则 改 革 进 展 缓 慢 以 及 标 准 制 定 组 织 的 规 则 固 化 的 背 景 下 ， 发 达 国 家 为 实 现 其 本 国 技 术 优 势 的 转 化 ， 在 多 边 贸 易 争 端 解 决 机 制 外 制 定 技 术 标 准 定 价 规 则 ， 以 实 现 技 术 价 值 的 最 大 转 化 。 但 由 于 专 利 价 值 分 摊 法 的 适 用 ， 司 法 机 关 可 根 据 本 国 的 产 业 政 策 在 确 定 专 利 价 值 过 程 中 自 由 裁 量 ， 导 致 标 准 必 要 专 利 许 可 费 的 司 法 定 价 在 权 利 人 与 实 施 者 、 实 施 者 与 实 施 者 之 间 难 以 达 成 共 识 ， 使 得 技 术 标 准 商 品 在 不 同 市 场 之 间 流 通 受 阻 ， 同

① 在确定每个标准必要专利的替代技术时，需要分析这些影响涉案专利的替代技术的价值，因该方法没有分析其所提出的替代技术之间是否相互矛盾，是否比标准中的专利更差，是否存在一个可行的功能衡量标准，从而转移了分析的重点。此外，替代技术的存在对涉案专利价值降低的影响程度，不仅取决于替代技术的自身质量，而且取决于一系列法律因素的变量，包括替代技术是否是非专利的、到期的，是否之前为标准中的部分专利，是否由另一主体授权他人免费或低价使用。

② 参见王宏禹、张晓通：《国际贸易秩序演变与国家间贸易争端管理》，陈玉刚主编：《国际秩序与国际秩序观》，上海：上海人民出版社，2014年，第57—69页。

③ 参见张磊：《维护开放透明包容的多边贸易体制》，《人民日报》2016年4月12日，第7版。

时引发资源的不均衡流动,最终形成非关税贸易壁垒。在意识到自行制定标准必要专利定价规则仅为一项权宜之计后,各国司法机关尝试解决标准必要专利定价规则的碎片化问题,向标准必要专利定价规则中注入稳定因素,维护技术贸易的多边体制。

二、多边贸易中技术标准定价规则的整合

当前,多边贸易体制虽遭遇困境,但各国已逐渐认识到多边贸易体制向前发展的现实必要性。面对技术标准定价规则碎片化对多边贸易体制的冲击,各国法院尝试通过对技术标准定价规则的整合,将其引入多边贸易的规则体系,而可比许可协议法正是这样的一次整合尝试,其试图将市场因素引入标准必要专利的定价规则。

(一) 技术标准定价规则的整合尝试

可比许可协议是与诉讼中所争议的假定性许可协议具有充分可比性的协议,^①充分的可比性是建立在已有的许可协议与假定性许可协议之间关联性足够强基础之上的。可比许可协议提供了确凿证据来证明涉案专利许可费的构成,最清晰地反映了专利技术在市场中的经济价值。^②因此,可比许可协议法规避了专利价值分摊法自身缺陷所致的出错风险。^③在以可比许可协议法确定许可费率时,并不能直观地确定同一专利的具体许可费率,多数情况下会受到复杂因素的干扰,复杂因素主要可划分为两种类型:一是在可参考的许可协议中涉及许可费的一次性支付,且一次性支付的金额往往不是简单地根据许可双方对潜在的产品销售数量估算的结果;二是可参考的许可协议涉及交叉许可,协议中明确约定的许可费是交叉许可专利许可费的差额。此外,其他因素诸如不同地区的专利强度,以及涉及的与专利许可无关的专利转让或销售等。在复杂因素影响下,尤其在涉及一次性支付和交叉许可的情形中,法院往往选择对许可协议进行解析,推导涉案专利的许可费率。

许可费的一次性支付是专利权人对实施者预期经营风险的一种规避措施,当专利权人预期专利许可人实施规模不会很大,或存在较大潜在实施和销售风险时,倾

① Virnetx, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014).

② Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).

③ 专利价值分摊法依据有限的证据、有限的信息、有限的认知能力和有限的审理时间所确定的专利许可费率不免有一定推测性。例如,华为诉 IDC 合理许可费确认案是全球范围内第一件由法院确定具体合理许可费率的标准必要专利许可案,虽然一审法院提出了计算标准必要专利许可费的四个注意要点,而这四个注意要点指引的方向是专利价值分摊法,但由于证据的缺乏和法官的有限认知能力,最终选择了可比许可协议法确定具体的许可费率。参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第306号民事判决书。

向采用许可费的一次性支付，否则倾向采用提成方式。^① 当涉及许可费的一次性支付时，需区分在支付许可费时是否已发生侵权，因被许可人往往通过一次性付款解决过去未经授权许可的产品销售。对于过去没有获得授权许可的销售，之后达成的协议可推定包括对前者的追认。在一次性支付的许可费数额中，区分为将来许可所支付费用和为无许可所补交的许可费，是在一次性支付中解析出可比基准的关键。有观点以销售额为区分标准，以已经发生的销售额与未来潜在的销售总额，确定所支付的初始一次性付款与未来的费率，除非有其他证据表明被许可人将部分初始一次性付款分配给未来的销售总额。^② 但因销售数据可能是历史数据或未来估值，且销售数据无法表明谈判者在许可谈判时的想法，如此便产生了不确定性。^③ 此外，也有观点提出以时间为标准，以时间长度为准均分一次性支付许可费。^④ 但以时间为区分标准易使问题的真实性受到质疑，所得许可费率的参考价值较小。

许可谈判的复杂性决定了解析一次性支付许可费的难度。专利权人和实施者在就许可协议谈判时，可能就无授权许可销售的存在达成共识，还有可能正在进行着诉讼，将已完成的销售视为许可协议前瞻性条款的组成部分，作为同一交易的部分支付相应许可费，是协议双方的惯常做法。但双方通常更关心的是所应支付和收取的许可费总额，而非是否应将支付金额区分为对过去的赔偿和对将来的许可；且被许可人往往倾向于选择一次性支付较高的许可费总额，以换取较低的许可费率或较低的许可费上限和下限。此外，即使双方同意针对过去许可和未来许可适用不同费率，通过计算得出的单向许可费率可能同样不准确。在对约定一次性支付许可费条款的可比许可协议解析时，不能忽视许可费谈判过程中可能存在的上述情形，以及在FRAND的约束下双方倾向于以更为友好的方式达成协议的事实，否则，所解析出的单向专利许可费率是缺乏事实基础的。因此，从约定一次性支付许可费的可比许可协议中解析的专利单向许可费率，在无其他证据予以佐证时当事人是难以接受的。

在交叉许可中，双方相互获得另一方专利的许可使用，在许可费不对等的情形下，由支付许可费较低的一方以现金或其他方式弥补差额，这种支付现金差额的方式被称为净平衡支付。该数据是许可协议中明确的许可费数据，根据该数据并借助

① 对于专利许可人和被许可人都存在且无法避免的风险是：双方是对未来的预估，未来总是不确定的。参见马海生：《标准必要专利许可费司法定价之惑》，《知识产权》2016年第12期。

② TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

③ Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd., [2017] EWHC 2988 (Pat).

④ TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

相关公式理论上可计算出专利许可双方各自许可专利的单向费率。^① 在既有判例中，^② 关于计算交叉许可中涉案专利的单向许可费率公式为：

$$\text{净平衡支付} = (\text{许可方单向费率} \times \text{被许可人收入}) - (\text{被许可方单向费率} \times \text{许可方收入})$$

公式中有两个未知变量：许可方的单向费率和被许可方的单向费率。为了解答这个公式，双方当事人使用专利组合强度比（PSR）来表示被许可人的单向费率作为许可方单向费率的比率，^③ 即：

$$\text{专利组合强度比} = \frac{\text{许可方单向许可费率}}{\text{被许可方单向许可费率}}$$

那么，许可方的单向许可费率就可用专利组合强度比予以表达，最后的解析公式可为：

$$\text{许可方单向许可费率} = \frac{\text{净平衡支付}}{\text{被许可人收入} - \frac{\text{许可方收入}}{\text{专利组合强度比}}} \quad \text{④}$$

但该公式一次只能用于一个标准专利，根据每个标准专利单独确定专利组合强度比，若被许可人向许可人一次性支付多个标准专利的许可费用，便无法适用该公式。

该公式基于确定数据可准确计算出涉案专利的单向费率，但在适用过程中，数据的确定性往往难以得到保证。在交叉许可协议中，许可费差额数据往往无法精确反映双方交叉许可专利市场价值的差额。交叉许可中许可人的单向许可费率可能低于在非交叉许可中的许可费率，从而借助较低的许可费率获得被许可人的专利许可，而对费率被压低的程度也难以测算。为了获取确定的费率数据，有观点提出通过披露与谈判相关文件和事实的途径，以获取许可人在所订立交叉许可协议中的许可费率情况，但这种对许可谈判开展事后调查的披露并不合理，虽然在理论上这可以免去解析许可协议的必要，但这种披露并不会给解析可比协议带来帮助，而只会产生新一轮毫无意义的争论。^⑤ 尽管解析公式中所采用的数据考虑到了各种不确定性并作出了相应假设，但也承认了数据本身的不确定性。

① 若净平衡支付的方式是一次性支付，则所确定涉案专利许可费率将会因上文所述的不确定性而削弱可比许可协议的参考价值。

② TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 JVS(DFMx) Consolidated with CV 15-2370 JVS(DFMx)(2017).

③ 若以专利组合强度比表示许可方的单向许可费率，则需要双方依据的基础费率必须一致。

④ 净平衡支付和收入必须以同年的货币表示，而这通常需要确定过去和未来支付和收入的净现值。

⑤ Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd., [2017] EWHC 2988 (Pat).

（二）技术标准定价规则的整合失败

可比许可协议法为标准必要专利许可费的确定提供了一种更为实证的定价规则，该方法注重在市场作用下已形成的许可费率标准，所得许可费率更能为双方当事人所接受。但可参考的许可协议多是在复杂因素影响下形成，从中解析出涉案专利的许可费率难度较高。在确定单向专利许可费率过程中，存在诸多的不确定风险，尤其表现为可比许可协议当事人在谈判过程中往往以友好的方式达成最终的许可协议，该友好谈判包含了不可预料的影响涉案专利许可费之判定的因素。过多不确定信息无法通过许可协议条款知悉，使司法机关能对不确定信息的获取途径和作用进行有意安排，以裁决出符合其所设定目标的许可费率。可比许可协议法的适用，旨在增加市场因素在许可费确定规则中的比重，减弱对专利价值分摊法的依赖，以整合和统一分散的标准必要专利定价规则，但复杂因素使得从可参照的许可协议中解析出涉案专利价值的过程变得艰难，最终可比许可协议法异化为专利价值分摊法。

虽未能成功整合标准必要专利定价规则，但各国司法机关试图以可比许可协议法替代专利价值分摊法所反馈的信息具有重要价值：其一，各国已意识到，专利价值分摊法所引发的技术标准定价规则的碎片化，引发了多边技术贸易领域中的单边主义，无论其产生是主动或被动，客观上都破坏了多边贸易体制；其二，确立市场因素在技术标准定价规则中的主导地位，正在各国之间逐渐形成共识，而该共识正是对多边贸易规则在确保技术贸易健康发展中作用的认可，因多边贸易体制的核心在于发挥市场在资源流通中的主导作用，虽然可比许可协议法未能成功将市场因素引入定价规则之中，但仅是证明了其引入方式的不适当。因此，进一步整合技术标准定价规则，应坚持贸易的多边主义，将市场这一稳定性因素注入技术标准的定价规则之中，这就要求在多边贸易体制之内进行探索，而非在体制之外另立规则。

三、技术标准市场定价与多边贸易规则的现代化

当前国际贸易治理结构正处于调整期，各国有关产业保护的利益诉求存在较大差异，维持现有多边贸易规则变得艰难，调整势在必行。作为多边贸易体制中商品流通的主导因素，市场应成为推动多边贸易秩序不断向前发展的内在动力，不断变革阻碍多边贸易市场发展的贸易规则。在技术标准定价规则中，鉴于影响标准必要专利价值的因素极为复杂，^① 在专利价值分摊法陷入困境以及可比许可协议法尝试

① 根据专利价值评估理论学者的研究，专利价值影响因素包括技术因素、法律因素和经济因素。技术因素包括先进性、行业发展趋势、使用范围、配套技术依存度、可替代性、成熟度；法律因素包括稳定性、不可规避性，专利侵权可判断性、有效期、多国申请、专利许可状况、依赖性；经济因素包括市场应用情况、市场前景规模、市场占有率、

失败的情形下，只有通过技术价格自发生成机制才能涵盖无法被掌控的复杂信息，自发生成机制是一种信息收集机制，能够使广泛散布的信息公之于众并使其得到利用，该机制即为市场定价规则。

（一）技术标准的市场定价规则

作为市场经济中用以约束市场主体的行为规范，市场规则是人为设定的关于市场交易的行为规范。^①而在市场交易行为规范约束下，市场主体自发形成的标准必要专利的许可费率是符合 FRAND 原则内在要求的，这源于该原则对市场主体自由意志的保障。标准制定组织要求标准制定参与者所作的 FRAND 承诺，首先表现为要求其实施者所达成的许可费要符合 FRAND 原则，而结果的达成则依赖在谈判过程中当事人达成协议的行为，因此，不仅需要用 FRAND 原则规制最终的许可方案结果，且需要以它调整许可方案达成的过程，以 FRAND 原则规制权利人和实施者的协议行为。权利人可按照 FRAND 原则所规定的路径开展谈判，并根据该原则授予技术许可；实施者若希望依据 FRAND 原则对权利人施加约束，其前提是遵照 FRAND 路径展开协商，并依据 FRAND 原则接受技术许可。标准必要专利许可费的协商过程，并不排斥当事人提出的许可费率高于真实的 FRAND 费率要约，这并不违背 FRAND 原则。因为，在双方当事人达成共识的过程中，讨价还价理论的一个关键原则是用双方威胁点以及谈判技巧促使双方达成最终的谈判结果，这决定了双方从所达成交易中获得预期收益如何分割，双方均会为各自的下一步退让保留余地。但提出极端要约和采取妨碍公平、合理和无歧视的不妥协做法是不能被允许的，这种恶意行为违背了善意协商的要求，且违背了 FRAND 原则。

FRAND 原则仅规制许可协议结果的观点是危险的。FRAND 原则内容的概括性特征，导致了标准必要专利权利人和实施者围绕各自的许可费率要约所产生的争议，即便所提出的许可费率要约符合 FRAND 原则，但当事人无法对此予以确认，从而致使他们愈发依赖法院对专利的定价裁决。法院是在考虑各种情况之后对双方就标准必要专利的许可费率作出的强制性裁定，无论这种裁定是否符合有限的证据，其所释放的信号，是对双方谈判确定费率之自由意志的伤害，这种问题解决路径最终不是让问题越来越清晰，而是使得问题的解决堆积在大量问题的暂时潜伏之上，当以后出现触发问题的激发点时，所有的矛盾将集中爆发。^② 依赖法院对标准必要

竞争情况、政策适应性。参见国家知识产权局专利管理司、中国技术交易所编：《专利价值分析指标体系操作手册》，北京：知识产权出版社，2012 年，第 10—29 页。

① 市场规则既包括由国家认可的约束市场主体经济活动的政策法规这类正式的市场规则，也包括由社会共同认可的、不成文的关于市场主体的行为规范，其中包括交易习惯等非正式市场规则。

② Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd., [2017] EWHC 2988 (Pat).

许可费率所作出的裁定，是痴迷于个人理性的表现，迷信法官可以得出一个完美的解决方案。这种痴迷是导致大量的许可费纠纷案件涌至法院的原因，而所得方案一旦被公众质疑，将会破坏法院公信力和司法权威。

在标准必要专利许可费的谈判中，许可人和被许可人都具有达成共识的强烈愿望，作为理性的市场主体，皆有能力对关于涉案标准必要专利所可能遭遇到的风险进行合理预期，并对这种风险作出合理的安排。在 FRAND 原则为当事人提供了预判潜在风险工具的同时，违反 FRAND 原则也被视为一种风险。依赖法院对标准必要专利许可费的裁定，便是要求法院对涉案专利权人和实施者将要面临的潜在风险皆要有所预期，这种要求是不合理的。在适用专利价值分摊法和可比许可协议法时，法院对具体涉案专利许可费的确定，往往是基于双方不存在较大分歧这一前提而进行的，^① 司法定价实质上难以脱离双方当事人就某些事项所达成的共识。对 FRAND 原则规制对象的重新审视，为转换解决问题的思路作了铺垫，即要求法院对一般适用原则予以分析，不再要求其判断具体风险的特殊性。

技术标准的定价规则关系到产业的发展变化和技术更新，应避免过于僵化的定价模式。Lemley 和 Shapiro 提出了以仲裁程序为标准必要专利许可费争议的解决方案，该方案使专利权人与任何自愿的被许可人就合理许可费进行仲裁。此仲裁模式为棒球式 (baseball-style arbitration)，在此仲裁模式下，每一方都向仲裁者提交最终要约，然后仲裁者必须从这两项要约中选择其一。^② 此仲裁方式植根于合作博弈理论，其本质是尊重市场在标准必要专利定价规则中的决定性作用。仲裁者在标准必要专利权利人和实施者提出的两项许可费报价中选择，如此将会促使双方在关于何种报价更能为仲裁者所接受的指引下，提出更为合理的许可费率要约，使双方的报价能以竞争的状态不断靠近 FRAND 原则的要求。而关于最终结果的确定主动权仍为仲裁者所掌控，对于许可费率值确定过程中的风险则交由发出要约者进行评估，尊重双方当事人在私下谈判过程中的自由意志，这是尊重市场作用的表现。^③

① 在适用专利价值分摊法的过程中，对于专利计数法的适用是以双方当事人对均等涉案专利价值不存在分歧为基础的；而在运用可比许可协议法时，已经凸显了法院对当事人之间达成的协议的重视。

② Mark A. Lemley and Carl Shapiro, "A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents," *Berkeley Technology Law Journal*, vol.28, no.2, 2013, pp.1135,1138.

③ 有反对者认为，FRAND 报价不仅包含价格，而且还包含条款和条件，不容易被标准化，更不用说总结为单个数字，且该模式不会裁定何种许可费率是公平、合理和非歧视的；这是一种重新定义专利权的路线图，将财富从发明者转移到侵权者身上。(J. Gregory Sidak, "Mandating Final-Offer Arbitration of FRAND Royalties for Standard-Essential Patents," *Stanford Technology Law Review*, vol.18, no.1, 2014, pp.1, 37-38) 然而，这种反对观点仍是以追求专利客观价值为目标确定符合 FRAND 原则的许可费。

上述仲裁模式为新方案提供的启示在于,不同条件下同一标准必要专利许可费率是不可能一致的,这使得追求统一许可费率的目标基础被动摇。当事人在谈判中所提出的标准必要专利许可费要约不再处于被动地位,即不受统一目标的支配。基于该方案的启示,本文尝试提出以市场为决定因素的标准必要专利司法定价规则,亦即以双方在谈判中提出的要约为主导,保留双方当事人在自由意志条件下就标准必要专利市场价值所形成的要约:根据双方当事人在谈判中所提供的许可费报价,法院所裁定的最终许可费率从中选择其一,不再提出新的许可费率标准;而法院根据要约确定过程中的条件和依据,认定和选择更符合FRAND原则的要约,即依据双方当事人在谈判过程中是否出现违背FRAND原则要求的情形,不再依据要约是否偏离统一的标准必要专利客观价值作出裁判。这一裁决过程将使得裁决结果较之一般专利许可费诉讼更易于预测,而就所提议的标准必要专利许可费特殊司法裁决程序的具体设置,可根据各国法院的自身特征进行规划。

该定价规则依赖当事人在谈判中提出的要约,故确保谈判过程能够体现当事人的自由意志极为重要。这要求双方以诚信态度从事谈判,而非以第三方裁判替代当事人的许可谈判。因此,法院对标准必要专利许可费的裁判应当在双方以诚信态度充分协商仍不能消除分歧的情况下进行,若经法院审理查明一方在谈判中存在不诚信行为,则在考量该方当事人所提供的要约是否应被选择时,应判定其处于不利地位。^①谈判中的不诚信行为主要包括:恶意磋商,一方当事人并非为达成最终的标准必要专利许可协议而谈判,而是将谈判视为一种实现其他不正当目的的手段;故意隐瞒与许可协议订立有关的信息,而该信息对协议的达成有重要影响;其他不诚信的行为。需注意的是,对谈判过程中不诚信行为的举证,要围绕的是行为对标准必要专利许可费的确定能产生的实质影响,而不能将不诚信行为的举证泛化。由于标准必要专利许可谈判过程也是FRAND原则的规制对象,任何不诚信的行为都会被视作对FRAND原则的违反,相关要约在被选择时的不利地位,可视为是对行为主体的惩罚。

此外,在该定价规则中,裁决者无需判定任何既有的专利是否有效。对于涉案标准必要专利是否有效的问题,权利人和实施者在谈判时会对此予以考量,并在此基础上提出其认为合理的许可费要约。在建议的定价规则中,法院不再追求以专利为基础确定合理许可费,符合FRAND的假设性谈判并不假定所涉及的标准必要专利都有效。当然,并不能否定专利的有效性对确定标准必要专利许可费的重要性,双方在提交的许可费要约的相关证据中,会涉及对专利有效性的初步判断,而法官在判断哪一种许可费率更为合理时,也会对标准必要专利有效性的证据进行判断。而就专利的必要性而言,当专利权人宣称非必要专利为必要时,其就将该项专利限

① 赵启杉:《标准必要专利合理许可费的司法确定问题研究》,《知识产权》2017年第7期。

定于这一特定的裁决程序；若不将该专利视为标准真正必要的专利，专利权人则可另案起诉并强制执行或寻求禁令。专利权人若自愿放弃这些救济途径，则风险仅由其自身承担。而对于权利人声称标准必要专利为非必要的情形，相对风险较大，因权利人试图避免或缩小 FRAND 原则对真正必要专利的规制范围。^① 该部分专利虽在标准必要专利许可费中无法获得相应比例，但其往往与其他标准必要专利组合发挥作用，实施者必须在标准之外支付许可费，且无法适用标准必要专利许可费特有的裁决程序，只能另案起诉。^②

个体是自身利益的最佳判断者。由标准必要专利权利人与被许可人通过谈判为技术标准定价，揭示了技术标准的价格取决于市场需求的本质。^③ 与传统产品的生产方规模经济不同，针对具有大额的沉默成本、趋零的边际生产成本、交叉网络外部性等显著特征的技术标准而言，需求方规模经济性决定其价格结构。^④ 因此，在竞争充分的市场条件下，技术标准价格的制定应以需求为导向，即先考虑实施者的需求强弱和价格接受能力，而后考虑能否弥补成本，这就要求权利人根据实施者对专利价值的认识和理解来为技术标准定价。区分需求定价则意味着以不反映技术成本费用差异的价格差异来分别对待不同的实施者，通过制定合适的价格结构，可将更多的实施者吸引到交易平台购买技术标准许可，从而使得技术标准持有者的权益最大化。技术标准的非竞争性消费，且其价格接受方是由双边甚至多边市场的实施者构成，其价格结构不反映成本结构，共同决定了技术标准价格结构的多元化。而技术标准的司法定价以权利人与实施者之间的价格要约为基础，正是尊重技术标准价格结构客观性的表现，同一技术标准的不同实施者被裁决的价格可能是不一致的。^⑤

从本质上而言，技术标准价格结构多元化的形成，源于技术标准生命周期的阶段特征。在技术标准生命周期内，技术标准的价格是动态变化的。导入期是技术标准生命周期中的关键时期，此时供给直线上升导致需求的急速膨胀，为获得先入者优势，技术标准持有者会选择让渡自身利益，通过渗透定价策略获得市占率，技术

① Mark A. Lemley and Carl Shapiro, “A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents,” pp.1135,1154.

② 另案起诉是否能成功获得救济则存在疑问，因为成功否认其专利对标准必要的专利权人往往难以说服法院认为产品侵权仅是因为它与标准相符合。参见 Mark A. Lemley and Carl Shapiro, “A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents,” pp.1135,1154-1155.

③ 参见赵启杉：《标准必要专利合理许可费的司法确定问题研究》，《知识产权》2017 年第 7 期。

④ 参见张运生：《高科技企业创新生态系统技术标准许可定价研究》，《中国软科学》2010 年第 9 期。

⑤ 这种司法裁决结果可能会给当事人造成形式上同一产品不同价格的不公平印象，但实际上，其正是追求实质公平的结果。

标准的定价可能低于其边际成本。而技术标准成长期的定价策略则突出多元化,技术标准持有者在实施者可能接受的最高价格与自己可以接受的最低价格间制定针对性价格,用多个价格甄别技术标准实施者,避免将实施意愿较低的实施者排除在市场之外。技术标准成熟期市场饱和,使技术标准权利人对产权保护进入抛物线顶峰阶段,对实施者的定价策略基本沿袭了成长期的歧视定价,并加快版本升级、缩短专利更新周期。衰退期指技术标准进入淘汰阶段,许可量和利润持续下降。此时虽然技术标准已经广泛确立,过于成熟的技术也罕有创新优势,此阶段企业以低价策略获取市场最后残余利润,同时转向全新市场,以期进入下一个生命周期。

(二) 多边贸易规则的现代化

所提议的技术标准定价规则方案的本质在于,技术贸易的争端解决由法院的强制干预定价转变为以市场规则为主导。这种转变是多边贸易规则增强其经济适应性的需要。就经济全球化发展的轨迹而言,现有多边贸易体制持续遭到破坏,其根源在于多边贸易的规则难以满足全球价值链新发展的利益诉求,导致处于价值链上层的成员绕开多边贸易体制另立规则,由此单边主义盛行和多边贸易体制被边缘化。尤其是随着新技术革命的不断推进,技术贸易正逐渐在全球化贸易中占据愈来愈重的份额,技术已成为主导全球价值链的核心要素,为了最大化实现技术在全球范围内价值转化,技术标准更是成为各经济体竞相追逐的对象。而现有多边贸易规则体系是基于传统价值链主导因素而形成的,无法满足新技术革命环境下各成员的利益诉求,尤其是贸易争端解决机制,如此便引发了各国法院就标准必要专利定价规则不一致的做法,多边技术贸易领域中的单边主义和保护主义由此产生,直接导致现有多边贸易规则体系的有效性和权威性被破坏。

多边贸易体制是经济全球化健康发展的基石,单边主义不符合世界经济的历史潮流,这是解决任何国际贸易争端都应坚持的共识。因此,面临现有多边贸易体制与全球价值链之间的冲突,唯一的解决方案是增强多边贸易规则体系的适应性,即对其进行现代化更新,如此便需要发展现有多边贸易规则。多边贸易体制秉持开放、透明、包容、非歧视等基本原则,其本质在于发挥市场在商品和服务流通中的主导地位,打破不同经济体之间的市场界限和贸易壁垒,为适应新的经济全球化形势,多边贸易规则的现代化则要求多边贸易体制重塑其维护市场经济的职能,以此破除违背市场规律的贸易单边主义。多边贸易争端解决机制作为多边贸易体制的核心内容,将市场因素注入具体的争端解决方案之中,可增强其可预见性和透明性,为市场主体创建稳定的预期的营商环境。在技术标准定价引起的贸易争端中,以市场规则统一标准必要专利许可费的确定规则,是消除各国司法机关裁定标准必要专利许可费规则林立的唯一有效途径,亦是促进多边贸易体制现代化的体现。



结语：多边贸易体制中技术定价的中国方案

维护和发挥多边贸易体制的作用，突出地反映在技术贸易领域中的技术标准定价规则的整合与转化。技术标准定价规则碎片化，其本质是在技术贸易领域内推行单边主义。单边主义在危害全球产业链和价值链安全、阻碍经济复苏步伐的同时，迫使现有多边贸易体制尽快改进，以增强其适应以技术标准为核心的全球价值链利益分配的能力。技术标准许可贸易天然地需要自由的市场，多边贸易体制是市场规律的外化表现，技术标准定价规则是多边贸易规则体系的核心内容。这就要求形成以市场为主导因素的技术标准定价规则，使得多边技术贸易体制重塑其维护自由市场的职能，推动多边技术贸易规则的现代化。多边贸易体制的改革是一项长期工程，各成员应意识到改革的紧迫性，发挥集体创造力，构建一套符合现实需要、广泛认可的系统解决方案和路线图，以多边贸易体制消除贸易的单边主义和保护主义。惟其如此，才能实现全球均衡、包容、普惠发展。

我国经济发展与多边贸易体制休戚与共。作为开放世界的受益者和贡献者，我国坚定支持多边贸易体制，打造全方位对外开放新格局，全面参与世贸组织各项工作，坚决反对单边主义，维护多边贸易体制的权威性和有效性，是多边贸易体制的积极参与者、坚定维护者和重要贡献者。倡导以市场为主导的技术标准司法定价规则，^① 尊重标准必要专利权人和实施者的市场行为，反对司法机关的干涉性定价，使同一技术标准以在不同市场内自发形成的价格得以推行，可以避免人为干预所产生的分歧和阻碍。同时，可以使得发展中国家在多边贸易体制内参与全球价值链分工，确保发展中国家尤其是最不发达国家共享全球技术革命的发展成果。这是我国改革开放 40 年来，知识产权治理由政府推动向市场驱动转变的成功经验，以期打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，与其他国家共同构建广泛的利益共同体，共同致力于人类命运共同体构建。

〔责任编辑：刘 鹏〕

^① 我国此种知识产权的治理经验集中反映在《外商投资法》第 22 条第 2 款，即“国家鼓励在外商投资过程中基于自愿原则和商业规则开展技术合作。技术合作的条件由投资各方遵循公平原则平等协商确定”。



charges are reviewing policy logic, evaluating policy performance, and driving policy implementation. Since the soft constraints on government finance are the main cause of increases in the macro tax burden, implementing a strategic plan of overall budget performance management and performance evaluation of government financial revenue, combined with instrumental and value rationality, provides a limiting mechanism and a system of standards for rationally curbing the unrestrained nature of government revenue maximization and for reconstructing national governance relationship. In this system, the cost of the burden of taxes and administrative charges reflects an orientation toward results, while tax pain foregrounds an orientation toward degree of satisfaction. The two become key indicators and important dimensions of evaluation. As is evident from both theory and experience, to avoid the “North paradox,” stimulate popular dynamism, and reverse engineer institutional reform, performance evaluation of government revenue can serve as a corrective mechanism for errors and biases in government financial policy-making and as a way of gauging tax levels. This will effectively curb tax increases, reduce the cost of taxes and administrative charges and lessen tax pain, as well as increasing the credibility and administrative capacity of public finance.

(6) Multilateral Trade, Market Rules and the Pricing of Technical Standards

Ma Yide • 106 •

The interactive use of technology hastens the adoption of technical standards, and trade in technical standards licensing is an important part of global multilateral trade. The pricing rules for unilateral technical standards have led to a large number of lawsuits, overwhelming technology-based market entities and giving them no time to upgrade their economic structures. The implementation of technical standards requires a fair, reasonable and non-discriminatory multilateral trade system. As the legal form of technical standards, the pricing rules for standard-essential patent licensing fee are core contents of the rules of multilateral trade in technology. The existing pricing rules show that different countries are engaged in actively or passively formulating self-interested unilateral rules outside the multilateral trade system, resulting in the fragmentation of technical standard pricing rules. Integrating technical pricing rules with market factors, reshaping the functions of the multilateral trade system, modernizing the rules of multilateral trade, and increasing the adaptability of the multilateral trade system in relation to global value chains are feasible solutions to pricing rule conflicts. China is a beneficiary and participant in the open economy. It should advocate the establishment of market-based standard-essential patent pricing rules so that countries with different levels of development can share in the fruits of the technological revolution under the multilateral trade system. This will promote global equilibrium and inclusive and universal development, and will thus contribute Chinese wisdom and a Chinese solution for the building of a community of shared future for mankind.